

2016 특허법 2차 시험 기출 해설

- 1) 해설 : 서평강 변리사
- 2) 답안 구성 : 김석준 변리사
권구성 변리사
김남혁 변리사
장현욱 변리사
서평강 변리사
조민지 변리사

<총 평>

1. 금번 특허법 2차 시험에서는 2015, 2016년 10대 판례 및 최근 전합 판례 등 평소 A급으로 여겨지던 문제들이 대거 출제 되었습니다.
2. 무엇을 묻는 것인지 혼동되는 문제도 일부 있었으나, 이러한 문제들도 기본서 범위를 벗어나지 않은 것으로 판단됩니다.
3. 답을 조금 틀리셨더라도 전반적으로 일반론+논리적 기재를 잘하셨으면 일정 수준 이상의 득점을 하실 수 있을 것이라 판단됩니다.

[문제-1] - 냉장고 구동 시스템 문제

I. 설문(1)

1. 소설문 1) - 피고 乙 항변의 성격 검토

(1)공정력

判例(97후1030)는 특허는 일단 등록이 된 이상 무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수는 없다고 하였다.

(2)무효의 항변

判例(91마540, 98다7209, 2012후4162)는 등록된 특허발명이 출원 전 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 i) 소위 신규성이 없는 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 하였으나 ii) 진보성이 없는 경우까지 법원이 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 하였다.

(3)권리남용의 항변

최근 判例(2010다95390)는 i) 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지과 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시 하였다.

(4)사안의 해결

i) 권리남용의 항변은 특허권의 권리범위 자체의 부정이 아닌 권리행사를 제한해달라는 취지의 항변이고, 무효의 항변은 무효심결에 관계없이 권리범위를 자체를 부정해달라는 취지의 항변이다. ii) 특허권의 당연 무효는 공정력상 인정될 수 없으며, iii) 침해소송에서도 진보성 하자를 이유로 권리범위 자체를 부정하기 위한 무효의 항변은 인정되지 않는 바 iv) 진보성 부정을 이유로 청구기각을 구하는 乙의 항변은, 진보성 하자있는 甲의 특허권에 기한 권리행사가 제한되어야 한다는 취지인 권리남용의 항변에 해당한다.

2. 소설문 2) - 법원의 특허발명에 대한 진보성 하자 심리·판단 가부

(1)법원이 권리남용의 항변 당부 전제로 甲 특허발명에 대한 진보성 판단 가부

1) 判例의 태도

과거 判例(91마540)는 법원이 특허발명의 진보성 존부를 판단하는 것에 대해 부정하는 입장이었으나, 최근 判例(2010다95390)는 특허권 침해소송을 심리하는 법원도 권리남용의 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대해 심리·판단할 수 있다고 하였다.

2) 사안의 해결

법원은 乙의 권리남용의 항변에 대한 당부를 판단하기 위한 전제로서 甲의 특허발명에 대한 진보성 인정여부에 대하여 심리·판단할 수 있다.

(2) 법원이 甲의 청구를 기각할 수 있는지 여부

1) 判例의 태도

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 및 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 하였다.

2) 검토

진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해 형식적으로 특허 등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 실시자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다는 점에서 최근 判例의 태도는 타당하다.

(3) 사안의 해결

i) 법원이 권리남용의 항변에 대한 당부를 판단하기 위한 전제로서 진보성 흠결을 판단한 결과 甲의 특허발명에 대한 진보성이 부정되어 무효로 될 것이 명백한 경우라면, ii) 법원은 진보성 하자있는 특허권에 기한 甲의 청구를 권리남용에 해당함을 이유로 기각할 수 있다.

II. 설문(2) - 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위 부정가부

1. 소극적 권리범위확인심판의 의의 및 심리방법

i) 소송절차에 앞서 분쟁을 조기해결 위한 절차로서 ii) 권리범위에 속하지 않는다고 판단되는 경우 인용심결 iii) 권리범위에 속하지 않음을 인정할

수 없는 경우 기각심결을 하며 iv) 주장자체로 이유 없는 경우 각하심결을 한다.

2. 甲의 X 발명에 신규성이 부정되는 경우의 취급

(1) 신규성 부정 시 권리범위를 부정할 수 있는지 여부

判例(91마540, 98다7209)는 등록된 특허발명이 출원 전 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 i) 소위 신규성이 없는 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 하였다. ii) 생각건대, 무효심판의 기능 약화가 초래될 수 있으나 특허권이 형식적으로 존재한다는 이유만으로 보호범위를 인정하는 것은 소송경제 및 구체적 타당성에 반하므로 판례의 태도는 타당하다고 판단된다.

(2) 심판원의 조치

심리결과 甲의 X발명의 신규성이 부정되는 경우, 甲의 특허권의 권리범위를 부정할 수 있으므로, 심판원은 乙의 소극적 권리범위확인심판에 대하여 X발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 인용심결을 할 것이다.

3. 甲의 X발명에 진보성이 부정되는 경우의 취급

(1) 진보성 부정 시 권리범위를 부정할 수 있는지 여부

1) 전원합의체 다수의견

判例(2012후4162)는 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지를 확인하기 위한 절차로서, 진보성 여부를 권리범위확인심판에서 판단하는 것은 권리범위확인심판 제도의 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않으며 무효심판의 기능을 약화시키는 것이므로 허용될 수 없다고 하면서, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다고 하였다.

2) 전원합의체 소수의견

判例(2012후4162)는 i) 신규성 및 진보성 모두 발명의 구성 및 효과 등을 종합하여 판단하고, 특허의 무효이유라는 점에서 차이가 없는 점 ii) 침해소송에 있어서 특허가 무효심판에 의해 무효로 될 것이 명백한 경우 침해가 인정될 여지가 없다는 것이 최근 전원합의체 판례의 취지라는 점 iii) 특허무효심판이나 권리범위확인심판이나 모두 심판원이 담당한다는 점 iv) 따라서 특허발명에 진보성함결의 무효이유가 명백한 경우라면 그 특허권을 근거로 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없어 부적법 각하되어야 한다고 한다.

3) 검 토

i) 권리범위확인심판은 특허가 유효함을 전제로 의미를 갖는 것이고, ii) 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 하계끔 하는 것은 과도한 심리부담을 야기하며, iii) 권리범위확인심판은 민사소송과는 달리 대세효를 갖는다는 점 및 iv) 권한분배의 원칙을 고려할 때, 최근 判例(2012후4162)의 태도가 타당하다.

(2) 대인적(對人的)인 특허권 행사의 제한사유를 주장하는 경우 취급

상표 관련 判例(2012후1101)는 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다고 한다.

(3) 무효사유 명백한 특허권에 대한 권리범위확인심판의 경우 취급

상표 관련 判例(2011후3698)는 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우라면 그러한 상표등록을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.

(4) 심판원의 조치

i) 사안에서 乙은 소극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 진보성 흠결을 이유로 권리범위가 부정된다는 주장만을 하고 있는바, 상표 관련 判例를 유추할 때 이는 주장 자체로 이유 없는 주장으로 확인이 이익이 없는 심판청구이다. 따라서 ii) 심판원은 乙의 심판에 대하여 확인의 이익이 없다는 이유로 각하심결을 하거나 iii) 청구의 이유가 없다는 이유로 기각심결을 할 수 있다.

Ⅲ. 설문(3) - 심결취소소송의 심리범위

1. 문제점

특허소송의 경우 고도의 전문화된 분야를 다루고, 심결전치주의(法186⑥)를 취하고 있는 특수성이 있는바 일반 행정소송의 경우처럼 심판에서 주장하지 않은 사실에 대하여 심결취소소송 절차에서 심리하는 것이 허용될 수 있는

지 심결취소소송의 심리범위가 문제된다.

2. 심결취소소송 및 심결전치주의

(1) 심결취소소송의 의의 및 법적 성질 (法186조)

i) 심결당사자가 행정처분인 심결의 위법성을 소송을 통해 불복할 수 있는 제도이며, ii) 당사자의 권익을 피하기 위함이다. iii) 判例(2003후922)는 당사자계 사건에 관하여도 심결은 행정처분에 해당하므로 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송이라고 판시하여 항고소송으로 보고 있다.

(2) 심결전치주의(法186조6항)

i) 제186조 6항에서는 「심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.」라고 규정하여, 특허소송은 심결전치주의를 취한다. ii) 이는 발명의 성질상, 판단에 특수한 전문지식을 요하기 때문이다.

3. 심결취소소송의 심리범위

1) 견해의 대립

i) <무제한설>은 특허법원은 소송상의 제1심에 해당하고, 심결취소소송은 소송으로서 변론주의를 취하는 바, 당사자는 심결에서 판단된 바 없는 어떠한 위법사유도 주장·입증할 수 있고 법원도 자유로이 판결의 기초로 삼을 수 있다는 입장이며, ii) <제한설>은 심결전치주의를 근거로 특허법원을 사실상 2심으로 취급하며 고도의 전문화 된 특허심판원의 판단을 중시해야 하는 바, 심결에서 현출되지 않은 위법사유는 주장 내지 판결의 기초로 삼을 수 없다는 입장이다. iii) <절충설>은 결정계 심판은 제한설, 당사자계 심판은 무제한설이 타당하다고 한다. iv) 이외에 개별적 고찰설 등이 있다.

2) 당사자계 심판에 대한 심결취소소송의 경우 判例의 태도

判例(2007후4410)는 i) 기술심리관 제도를 두고 있어 그 특수성에 문제가 없으며, ii) 당사자의 공격방어방법을 제한하는 것은 헌법상 보장된 국민의 신속한 재판받을 권리를 침해하는 것이므로 심결에서 주장하지 않은 공격방어 방법의 제출이 가능하고 이에 대해 법원도 심리할 수 있다고 하여 무제한설의 입장이다.

3) 결정계 심판에 대한 심결취소소송의 경우 判例의 태도

判例(2001후1617)는 거절결정 불복심판에 대한 심결취소소송에서 특허청장이 새로운 거절이유¹⁾를 주장하는 것은 심사·심판 단계에서 출원인의 의견서 제출기회를 박탈하는 것으로 허용될 수 없다고 하였다.²⁾

4) 검 토

i) 직권탐지주의가 적용되는 심판절차는 주장하지 않은 사실도 심판의 대상물이 되고, 이는 곧 법원의 소송물이 되는바 특허법원의 심리범위는 무제한설에 따라 보는 것이 타당하다.

ii) 단, 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송의 경우 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출기회는 강행규정임을 고려할 때, 특허청장의 새로운 거절이유의 주장을 제한하는 判例의 태도가 당사자의 절차권 보장 취지에서 타당하다고 본다.

4. 사안의 해결 - 특허법원의 조치

(1) 무제한설(判例)에 의할 경우

i) 乙이 제기한 무효심판은 당사자계 심판이므로 무제한설에 의해 심리되는 바 ii) 특허법원은 乙이 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증한 것에 대해 판결의 기초로 삼을 수 있다. ii) 따라서, 乙이 새로이 주장한 것이 이유 있는 경우에는 인용판결을 하되 원 심결을 취소할 것이며, ii) 이유 없는 경우에는 기각판결 할 것이다.

(2) 제한설에 의할 경우

제한설을 따르는 경우 乙은 심결취소소송에서 새로운 사실을 주장·입증을 할 수 없는 바, 법원은 乙의 새로운 사실에 대한 주장을 배척할 것이며, 이 경우 특별한 사정이 없는 한 기각판결을 하며 원 심결을 유지할 것으로 본다.

<끝>

1) 判例(2001후1617)는 새로운 거절이유가 아니면 심결에서 판단되지 않은 사항을 심결의 결론을 정당하게 하는 사항으로 입증할 수 있다고 한다.

2) 새로운 거절이유인지는 i) 형식적으로는 거절이유 및 인용발명의 동일 여부를 고려하여 판단하되 ii) 실질적으로는 그러한 이유에 대하여 출원인이 심사단계 또는 심판단계에서 절차권 보장의 기회를 가졌는지 여부로 판단하여야 할 것이다.

[문제-2] - 반도체 웨이퍼 연마용 패드 문제

I. 설문(1) - 특허발명의 생산에만 사용하는 물건의 의미

1. 문제점

乙은 甲의 특허발명의 구성요소 모두를 실시하지는 않는 바, 직접침해는 문제되지 않으며, 간접침해의 성립과 관련 法127조에서 규정하는 ‘특허발명의 생산에만 사용하는 물건’에 해당되는지 문제된다.

2. 간접침해의 의의 (法127)

특허발명의 구성 모두를 실시하지 않아 직접침해는 아니지만, 직접침해의 전 단계로서 이를 그대로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 행위에 대해 특허권자를 실질적으로 보호하기 위해 침해로 의제하는 침해의 일 태양이다.

3. 간접침해의 요건 중 “특허발명의 생산에만 사용하는 물건”의 의미

(1) 특허발명의 “생산”에 사용될 것 - 공용성(共用性)

1) 공용성의 의미

간접침해 대상물이 특허발명의 실시에 사용되는 관계에 있어야 한다.

2) 제127조에서 규정하는 “생산”의 의미

判例(2007후3356)는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 구성 요소 모두를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하며, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함된다고 하였다.

(2) 특허발명의 생산“에만” 사용될 것 - 전용성(專用性)

1) 전용성의 의미

간접침해 대상물을 이용한 실시의 결과물이 오로지 특허발명으로만 귀결되는 관계에 있어야 한다. 즉, 타용도가 없음을 의미하며, 이 때, 실시의 결과물인 “특허발명”은 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등범위 또는 이용관계에 있는 발명까지 포함해석 한다.

2) 타용도의 의미

判例(98후2580)는 경제적, 상업적, 실용적인 타용도로의 사용사실이 있어야 하고, 이론적, 일시적, 실험적인 타용도로의 사용가능성만으로는 타용도가 있

다고 볼 수 없다고 판시하였다.

3) 타용도 유무의 판단시점 및 입증책임

i) 권리범위확인심판에서는 심결시, ii)침해금지청구의 경우, 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하며, iii)손해배상청구의 경우, 과거의 행위로 인한 손해회복이므로 간접침해 행위시를 기준으로 판단한다. iv)判例(2000다27602)는 간접침해에 관한 규정은 금지청구권 등의 권리발생요건에 관한 것이므로 특허권자에게 입증책임이 있다고 하였다.

4. 설문(1)의 해결

(1)乙의 실시(A+M+C)가 甲의 특허발명(A+B+C)의 ‘생산’에 사용되는지 여부
乙의 연마용 패드를 구입한 반도체 제조업체가 이를 이용할 때에, 이 연마용 패드는 A+M+b+C로만 나타나지만, b는 B로 실시하게 될 개연성이 큰 바, 결국 乙의 A+M+C는 甲의 특허발명 A+B+C를 모두 포함하는 발명인 A+M+B+C의 “생산”에 사용된다고 볼 수 있다.

(2)乙의 실시(A+M+C)가 甲의 특허발명(A+B+C)의 생산‘에만’ 사용되는지 여부
乙은 자신의 연마용 패드가 기존의 이용공정과 다른 방법으로 사용되는 경우에는 A+M+C로 발현될 수도 있다고 항변하고 있으나, 실제 시장에서는 기존 이용공정으로만 사용되고 있어, 위와 같은 막연한 사용가능성 만으로는 타용도가 인정되지 않을 것이다. 결국 乙의 연마용 패드를 구입한 반도체 제조업체가 이를 이용하는 경우, 이 연마용 패드는 A+M+b+C로만 나타날 것이고, b는 B로 실시하게 될 개연성이 큰 바, 결국 乙의 A+M+C는 甲의 특허발명 A+B+C를 모두 포함하는 발명인 A+M+B+C의 생산“에만” 사용된다고 볼 수 있다.

(3) 사안의 해결

乙의 연마용 패드는 특허물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당한다.

II.설문(2) - 法127조1호의 “생산”의 의미

1. 문제점 및 직접침해 여부

i) 丙은 반제품을 생산하는바 甲의 특허권의 구성요소 모두를 실시하지 않으므로 직접침해는 성립하지 않으며 ii) 수출은 특허법 2조3호에서 규정하는 실시태양이 아닌 바, 사안의 반제품 생산이 간접침해인지 문제된다.

2. 간접침해의 성립에 직접침해의 성립을 요건으로 하는지 여부

i) 청구범위를 초월한 효력범위를 인정하는 것은 부당하므로 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 전제되어야 한다는 <종속설>이 있으나, ii) 간접침해는 직접침해의 전단계이고, 法127조는 일정요건을 만족하면 간접침해로 간주하므로 문리해석 상 독립설의 태도가 타당하며, iii) 判例 또한 독립설 입장이다.

3. 法127조 특허발명의 ‘생산’이 외국에서의 생산을 포함하는지 여부

(1) 判例의 태도

判例는 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.”고 하였다.

(2) 검토

i) 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점, ii) 독립설을 따르면 法127조의 요건 충족 시 직접침해와는 별개로 간접침해가 성립될 수 있는 것이기는 하나, 이는 속지주의를 포함하는 특허법의 대원칙이 전제된 경우에 한해 성립되어야 할 것임을 고려할 때 법문보다 특허에 관한 전통적 원칙을 우선시 한 判例의 태도가 타당하다.

4. 사안의 경우

判例에 따를 때 丙이 국내에서 생산하여 수출한 반제품은 모두 제3국에서 완성품으로 생산되었으므로 甲 특허권에 대하여 특허법 제127조 제1호에 정한 “특허발명의 생산” 이라고 볼 수 없으므로, 간접침해는 성립되지 않는다. 결국, 丙의 제품은 직접침해 및 간접침해에 해당하지 않으므로, 甲의 침해주장은 부당하다고 판단된다. <끝>

[문제-3] - 공유 문제

I. 설문(1) - 특허권 공유의 법적 성격

1. 문제점

명시적으로 공유와 합유를 구분하고 있는 민법과 달리, 특허법은 특허권 공유에 관하여 명시적인 규정을 두고 있지 않은바, 그 법적 성격이 문제된다.

2. 견해의 대립

i) 특허권 공유자 간의 지분처분 및 실시권에 관하여 제한을 둔 法37③, 法99②④을 근거로 특허권의 공유는 합유로 보아야 한다는 <합유설>, ii) 무체재산권의 특성 상 法37③, 法99②④ 한도에서만 합유적 성질을 가질 뿐, 그 이외의 경우는 민법상 공유규정 적용된다며 공유로 보아야 한다는 <공유설>과 iii) 원칙 민법상 공유와 차이가 없으나, 특허법에서 그 권리행사에 제약을 가하는 규정이 있는 경우에는 그 범위 내에서 합유와 유사한 성질을 갖는다는 <절충설>이 대립한다.

3. 判例의 태도

判例(2002후567)는 공유특허권의 권리행사에 일정 제한에 따라 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가지나 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하지 아니하는 한 일반적으로는 민법상 공유에 관한 규정이 특허권의 공동소유에도 적용된다고 한다.

4. 검토

특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상 특허에 관한 권리를 준공유한다고 보아야 하므로 判例의 태도가 타당하다.

II. 설문(2) - 공유물 분할청구 가부 및 법원의 조치

1. 소설문 1)

(1)특허법 제99조제2항 및 제4항 규정의 취지

判例(2013다41578)는 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동은 가져올

수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다고 한다.

(2) 공유특허권에 대한 분할 청구권 인정여부

1) 공유물분할청구권(민법 제268조, 제269조)

민법상 공유자는 원칙적으로 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 다만, 특허권은 무체재산권으로 공유관계의 특수성이 있는바 공유특허권에 대한 분할청구권 인정여부가 문제된다.

2) 견해의 대립

i) 합유설의 입장에서 특허권의 지분에 대해 분할을 청구할 수 없다고 하는 <부정설>과, ii) 공유설의 입장에서 분쟁의 조기 해결을 위해 특허권의 지분에 대해 분할을 청구할 수 있다고 하는 <긍정설>이 대립한다.

3) 判例의 태도

최근 判例(2013다41578)는 특허권의 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권³⁾을 인정할 수 있고 이 경우 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 않는다고 한다.

4) 검토

공유물분할청구권을 인정하더라도 다른 공유자 지분의 경제적 가치변동이 발생한다고 보기 어렵고, 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용된다고 보는 判例의 태도가 타당하다.

(3) 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구권에 관한 규정 적용 여부

1) 判例의 태도

判例(2002후567)는 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하지 아니하는 한 일반적으로는 민법상 공유에 관한 규정이 특허권의 공동소유에도 적용된다고 한다.

2) 검토 및 사안의 해결

3) 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.(民法 268①)

특허권의 공유관계의 법적성질을 공유로 보는 점, 특허법에 공유물 분할을 금지하는 규정이 없다는 점에서 특허권의 공유관계에 민법상 공유물 분할청구권에 관한 규정이 적용될 수 있다.

2. 소설문 2)

(1) 특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부

1) 判例의 태도

최근 判例(2013다41578)는 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 않는다고 하였다.

2) 검토 및 사안

무체재산권인 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않으므로 判例의 태도가 타당하다. 따라서 甲과 乙은 특허권의 현물분할을 할 수 없을 것이다.

(2) 법원은 특허권에 대해 경매에 의한 대금분할을 명할 수 있는지 여부

1) 판례의 태도

判例(2013다41578)는 설문과 유사한 사안에서 현물분할은 허용하지 않았으나, 경매에 의한 대금 분할을 명하였다.

2) 검토 및 사안

특허권은 무체재산권으로 현물분할이 부적절한바, 대금분할을 명한 判例가 타당하다. 따라서 甲과 乙은 특허권의 경매에 의한 대금분할을 할 수 있을 것이다.

Ⅲ. 설문(3) - 심판 및 심결취소소송의 당사자 적격

1. 소설문 1)

(1) 丁이 제기한 무효심판의 피청구인 적격

1) 제139조제2항

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다. (제139조제2항) 判例는 공유인 특허권의 특허권자에 대한 심판은 고유필수적 공동심판으로 본다.

2) 사안의 해결

甲과 乙은 X발명에 대한 공유특허권자인 바, 丁이 청구한 X발명에 대한 무효심판의 피청구인 적격은 甲과 乙이 가진다.

(2) 적극적 권리범위확인심판에서 청구인 적격

1) 제139조제3항

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다. (제139조제3항) 判例는 공유인 특허권의 특허권자가 제기한 심판은 고유필수적 공동심판으로 본다.

2) 사안의 해결

甲과 乙은 X발명의 공유 특허권자인바, 공유권리인 X발명에 기하여 청구한 적극적 권리범위확인심판의 경우 甲과 乙이 청구인 적격을 가진다.

2. 소설문 2)

(1) 심결취소소송의 원고적격

- i) 심결취소소송은 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기 할 수 있다. (法186②)
- ii) 소송의 남용 및 소송지연을 방지하기 위하여 원고적격을 제한하고 있다.

(2) 공유자 중 1인의 심결취소소송의 원고적격

1) 문제점

심판청구에 있어서는 제139조 3항에 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다는 명문의 규정이 있으나, 심결취소소송의 경우에는 이러한 규정이 없어 문제된다.

2) 견해의 대립

- i) 특허권의 공유관계는 준합유의 관계로서 관리처분권이 공동귀속되며, 심결취소소송은 처분행위로서 전원이 함께 하여야 하는 고유필수적 공동소송인 바, <단독으로 심결취소소송을 제소할 수 없다고 보는 견해>
- ii) 공유자 간 관리처분권이 공동귀속되기는 하나, 심결취소소송은 보존행위에 해당하여 단독으로 제기할 수 있는 유사필수적 공동소송이므로, <공유자 각자가

심결취소소송을 제기할 수 있다고 보는 견해>가 대립한다.

3) 判例의 태도

i) 종래 특허법원 判例(98허7110)는 고유필수적 공동소송으로 보았으나⁴⁾
 ii) 최근 判例(2002후567)는 상표권과 관련하여 ① 상표권이 공유인 경우
 합유와 유사한 성질을 가지지만 이는 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유
 래한 것이고, 합유관계로 본다는 명문의 규정이 없는 이상 민법상 공유규정
 이 적용되며 ② 공유자 중 1인의 심결취소소송의 제기에 의해 승소한 경우
 판결이 합일확정 되는 점 ③ 패소한 경우에도 다른 공유자에게 특별한 피해
 가 없는 점 등을 고려할 때 공유자 1인이라도 당해 상표권의 권리행사에 있
 어서 방해배제를 위하여 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고 판시하여
 유사필수적 공동소송으로 본다.

4) 검 토

i) 공유물의 보존행위는 공유자 중 1인에 의해서도 가능한 점 ii) 특허권
 자의 보호 및 소송경제의 측면을 고려할 때 공유자 중 1인에 의한 심결취소
 소송의 소제기는 적법하다고 판단된다.

(3) 사안의 해결

심결취소소송은 유사필수적 공동소송인바, 甲 또는 乙은 각각 원고적격 가지
 며, 甲과 乙이 동시에 원고가 되어 소송을 수행할 수도 있다. <끝>

4) 다만, 종래 특허법원 判例(98허7110)는 고유필수적 공동소송으로 보아 제1심의 변론종결시까지 필수적 공동소송인의 추가(民訴法 68)를 하지 않으면
 부적법 각하할 것이라고 하였다.

[문제-4] - 강제집행 면탈 문제

I. 설문(1) 및 설문(2) - 이중양도 된 특허권의 유효성 검토

1. 특허를 받을 수 있는 권리 (法33조1항)

(1) 의의

i) 발명의 완성에 의하여 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, ii) 2인 이상 공동발명하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이며, iii) 특허권 발생 전까지 발명을 보호하기 위한 1차적 보호수단이다.

(2) 이전

i) 특허를 받을 수 있는 권리는 재산적 가치를 인정하여 이전이 가능하며 (法37①), ii) 출원 전의 승계에서 승계의 효력은 승계로서 발생하며 출원은 제3자 대항요건이고(法38①), iii) 출원 후의 승계에서 상속 기타 일반 승계를 제외하고 출원인 변경신고를 하여야 승계의 효력이 발생한다.(法38④)

(3) 흠결 시 취급

거절이유(法62), 정보제공사유(法63의2)에 해당하며, 착오로 등록되는 경우 무효사유(法133)에 해당한다.

2. 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도 허용여부

(1) i) 특허받을 수 있는 권리는 이전 가능한(法37①) 채권적인 권리로서 ii) 이중양도 자체는 원칙적으로 허용되며, 출원 전 이전은 출원이 제3자 대항요건인바, 이중양도 시 양도계약의 선후를 불문하고 먼저 출원한 자가 유효하게 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 된다.

(2) 단, 특허법원 判例(2005허9282)는 이중양도 행위가 발명자의 배임행위로서 양수인이 적극적으로 가담한 경우라면 민법 제103조 위반의 반사회적 법률행위로 무효로 보며, 양수인이 등록받은 특허 또한 무효로 보았다.

3. 설문(1)-소설문 1)

(1) 문제점

乙은 甲에게 판결에 기한 이행청구권을 가지고 있으며, 甲은 특허를 받을 수 있는 권리를 A회사에 이전하였는바, 이중양도가 문제된다.

(2) 이중양도 유효여부

i) 甲이 강제집행을 면탈할 목적으로 A회사를 설립한 행위는 이중양도 행위에 적극적으로 가담한 것으로 볼 수 있으며 ii) 甲이 A로 권리를 이전한 행위는 민법 제103조의 반사회적 법률행위로서, 결국 甲의 A 회사에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 무효이다.

(3) 사안의 해결

甲이 A에게 한 이중양도가 무효인 바, A 회사는 발명을 한 자 또는 승계인이 아니므로, A가 등록 받은 특허권은 法33①의 무효사유가 있다.

4. 설문 (1)-소설문 2)

(1) 특허권 이전등록 청구 거부

1) 乙이 A에게 직접 특허권이전등록청구가 가능한지 여부 - 소극

乙은 甲에 대해 확정판결에 기한 채무 이행청구권을 가지지만, A 회사에게 직접 채권적 청구권을 가지는 것은 아닌바, 乙은 A 회사에 대해 특허권을 양도할 것을 청구할 수 없다.

2) 乙이 甲의 피보전채권을 근거로 특허권이전등록청구의 대위행사 거부 - 적극

i) 甲이 A 회사에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한 것은 민법 제103조에 따라 무효인바, A 회사는 특허권을 부당이득하고 있으며, 이에 따라 甲은 A회사에 대하여 부당이득반환으로서 특허권을 이전등록할 것을 청구할 권리를 가진다.

ii) 따라서, 乙은 甲에 대한 채무 이행청구권을 피보전권리로 하되, 甲의 A 회사에 대한 이전등록청구권을 대위행사하여, 순차적으로 A 회사로부터 甲, 甲으로부터 乙로 특허권을 이전등록 받아 X발명에 대한 특허권을 가질 수 있다.

(2) 무효심판 및 정당권리자 출원

A 회사의 특허권은 法33① 무효사유가 있는바, 무효심판 인용심결 확정된 후, 정당권리자 출원(法35)을 할 수 있으나, 정당권리자 출원의 시기적 제한 및 무효심판 비용 등을 고려할 때, 특허권이전등록청구에 비해 실익이 적다.

5. 설문(2) - 이중양도 된 특허권의 유효성 검토

(1) 이중양도 유효여부

甲이 乙과 丙 각각에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으므로

이중양도에 해당한다. 다만, 단순히 특허를 받을 수 있는 권리의 양도 사실을 알고 있는 丙에게 양도한 것은, 丙의 적극가담에 의해 이중양도한 것이 아니므로, 계약자유 원칙 상 甲이 丙에 대하여 한 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도는 원칙적으로 유효하다.

(2) 사안의 해결 - 丙 특허권의 유효성

丙은 乙보다 발명을 먼저 출원하였고, 출원 전 2인 이상이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 경우 출원이 제3자 대항요건인 바, 丙은 제3자 대항요건을 갖춘 것으로 볼 수 있다(法38①). 따라서 丙의 특허권은 유효하다.

II. 설문(3) - 권리 양도계약의 무효·취소에 따른 정당한권리자의 조치

1. 문제점

甲이 X발명 및 Y발명에 대한 권리를 丁에게 양도한 후 계약이 무효 또는 취소되어, 丁은 X발명 및 Y발명에 대해 발명을 한 자 또는 승계인이 아니므로 위 권리를 부당이득 하고 위 권리에 대해 무권리자가 되었는데, 정당한권리자인 甲의 조치로서 특허권이전등록청구 및 무효심판과 정당한권리자출원이 가능한지 문제된다.

2. 丁에 대한 특허권이전등록청구

(1) 문제점

정당한권리자출원(法35조)은 반드시 무효심판청구를 수반하여야 하므로 시간, 비용의 측면에서 손해가 되는 바, 먼저 정당한권리자인 甲이 乙에게 특허권 이전등록청구를 제기할 수 있는지 검토한다.

(2) 判例의 태도

判例(2003다47218)는 출원 중 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고 그에 따라 출원인 명의변경이 이루어진 후 특허권이 설정등록된 후 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에는 양도인은 민법상 부당이득반환 법리를 적용하여 특허권 이전등록청구를 할 수 있다고 하였다.

(3) 검토 및 사안

i) 절차의 신속성 및 제3자 피해가 발생하지 않는 점을 고려할 때, 인정하는 것이 타당할 것이다. ii) 사안에서 丁은 X발명 및 Y발명에 대해 법률상 원인 없이 특허권을 얻게되는 이익을 얻고 있는바, 甲은 丁에 대하여 X발명

및 Y발명에 대한 특허권 이전등록청구를 할 수 있다.

3. 무효심판 및 정당권리자출원

발명을 한 자 또는 승계인이 아닌 丁 명의의 특허권은 法33① 무효사유가 있는 바, 이를 이유로 하는 무효심판을 청구한 후 인용심결이 확정되면, 甲은 소정의 요건 갖추어 정당권리자출원(法35)을 할 수 있다. 다만, 정당권리자 출원의 시기적 제한 및 무효심판 비용 등을 고려할 때, 앞서 검토한 특허권 이전등록청구에 비해 실익이 적다. <끝>

“이하여백”

그 동안 대단히 수고많으셨습니다.
여러분들 모두에게 좋은 결과가 있기를 기원합니다.
감사합니다.